

Ahmad Ziyad bin Abdul Hayei

lawan

Elly Nadia binti Mohd Emla

Norilah binti Abu Bakar

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Hussain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) 30 Mac 2023/ 8 Ramadhan 1444H]

[Kes Mal (Rayuan) No. 10000-028-0024-2020]

[Rayuan Terhadap Perintah Hak Jagaan Anak di bawah seksyen 82 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : En Ahmad Luqman Hakim bin Ahmad Lutfi
daripada Tetuan Ahmad Muhammad & Associates.

Peguam Syarie Responden : En Wan Amir Akram bin Zainal Abidin daripada Tetuan
Amir & Elly

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Rayuan ini difailkan oleh Perayu ke atas sebahagian keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam Selangor dalam kes Saman No. 10400-028-0471-2016 yang telah diputuskan pada 20/2/2020.
2. Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada hari yang sama dengan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah dibacakan iaitu pada 20/2/2020 dan telah memfailkan Alasan Rayuannya pada 30/10/2020 dengan memplidkan dua puluh empat (24) Alasan Rayuan sepertimana yang tertera di hlm. 140-146 Rekod Rayuan.

Fakta Kes

3. Perayu dan Responden telah bernikah pada 4/2/2013 dan telah bercerai pada 8/8/2016. Hasil perkahwinan, Perayu dan Responden telah dikurniakan seorang cahaya mata iaitu Toriq bin Ahmad Ziyad (No. Mykad: 140328-14-0133).
4. Pada 1/8/2016, Responden-responden telah memfailkan tuntutan hadhanah terhadap anak tersebut melalui kes Saman No.:10400-028-0471-2016 yang mana ketika itu anak tersebut berumur 2 tahun 4 bulan.
5. Pada 20/2/2020, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor telah memutuskan sebagaimana berikut –
 - 1) Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff berdasarkan seksyen 83 EUUKIS 2003.
 - 2) Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak yang bernama Toriq bin Ahmad Ziyad (No. Mykad: 140328-14-0133) (selepas ini dikenali sebagai anak tersebut) hendaklah diserahkan dan diberikan jagaan bersama antara Plaintiff 1 (ibu) dan Plaintiff 2 (nenek).
 - 3) Mahkamah memerintahkan Defendan (bapa) hendaklah diberikan hak lawatan harian anak-anak tersebut pada setiap minggu hari Ahad dari jam 9.30 pagi hingga jam 6.30 petang dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Plaintiff 1 dan Plaintiff 2.
 - 4) Mahkamah memerintahkan Plaintiff 1 dan Plaintiff 2 atau Defendan dan/atau wakilnya adalah dilarang dan ditegah daripada mencero boh atau

mengganggu Plaintiff atau Defendan semasa proses lawatan dengan anak tersebut

5) Mahkamah memerintahkan supaya mana-mana pihak ketiga termasuk badan-badan kerajaan atau secara khususnya tetapi tidak terhad kepada Jabatan Imigresen Malaysia, Polis Diraja Malaysia, badan-badan berkanun, dan/atau mana-mana pihak berkuasa yang lain hendaklah memberikan kerjasama dalam melaksanakan Perintah Mahkamah ini.

6) Sebarang kegagalan mematuhi Perintah ini adalah melakukan suatu penghinaan kepada Mahkamah dan dengan itu boleh dikomitkan ke penjara.

6. Perayu tidak berpuashati dengan terma 2 sehingga 3 penghakiman tersebut dan telah memfailkan rayuan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

7. Perayu di dalam rayuan ini telah mengemukakan dua puluh empat (24) Alasan Rayuan untuk diteliti dan dipertimbangkan oleh kami. Asas rayuan yang dikemukakan oleh Perayu adalah berhubung dengan hak penjagaan, hak bersama dan hak bermalam dengan anak tersebut yang berkaitan dengan terma 2 dan 3 Penghakiman Hadhanah bertarikh 20/2/2020.

8. Dua puluh empat (24) Alasan Rayuan yang dikemukakan oleh Pihak Perayu adalah berhubung-kait tiga (3) isu utama iaitu –

8.1. Kewajaran hak penjagaan kekal diberikan kepada Responden-responden;

- 8.2. Kewajaran hak bersama dan bermalam diberikan kepada Perayu;
 - 8.3. Kewajaran YA Hakim Bicara mempertimbangkan atau mengulas setiap tuntutan balas Perayu untuk dijadikan sebagai terma penghakiman.
9. Sukacita kami nyatakan bahawa kondisi anak yang menjadi '*subject matter*' bagi kes ini adalah melibat seorang kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun 4 bulan semasa kes difailkan dan semasa keputusan Mahkamah Tinggi Syariah diberikan pada 20/2/2020 anak tersebut berumur 5 tahun 11 bulan yang mana anak ini masih belum mumaiyiz.

Isu Pertama: Kewajaran hak penjagaan kekal diberikan kepada Responden-responden

10. Perayu dalam Alasan Rayuan menyatakan bahawa Mahkamah Bicara telah *terkhalaf* dalam penghakimannya dengan memberikan hak jagaan anak tersebut kepada Responden-responden sedangkan timbulnya dakwaan bahawa Responden 1 menghidapi penyakit Bipolar Depression yang menyebabkan Responden 1 sering mengalami sifat marah yang melampau. Walaupun terdapat keterangan menyatakan Responden 1 telah sihat namun sifat marah melampau tersebut masih berterusan dan memerlukan rawatan yang berpanjangan bagi mengurangkan simptom penyakit tersebut berulang. Keadaan ini tidak melayakkan Responden 1 untuk menjaga anak tersebut.
11. Kami merujuk Alasan Penghakiman Hakim Bicara di para 13 sehingga 16 di hlm. 127-128 Rekod Rayuan yang mana YA Hakim Bicara menyatakan bahawa walaupun Defendan membangkitkan isu berkaitan penyakit Bipolar Depression yang dihidapi oleh Responden 1 namun Responden 1 telah mengemukakan satu laporan perubatan yang menyatakan bahawa Responden telah sihat daripada penyakit tersebut.

12. Laporan perubatan oleh doktor pakar yang merawat Responden 1 bagi penyakit Bipolar Depression tersebut yang bertarikh 26/10/2016 sebagaimana tertera di Ekshibit EN-04 di hlm 169 Rekod Rayuan menyatakan bahawa *"Pada pendapat saya, Puan Elly Nadia berada dalam keadaan kesihatan yang baik dan telah dapat mengekalkan pekerjaan dan menjaga anaknya."*
13. Kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara di para 15 hlm 128 Rekod Rayuan bahawa walaupun timbulnya fakta bahawa Responden 1 mengalami keadaan marah yang melampau namun keadaan tersebut tidaklah sehingga menjejaskan kebajikan anak tersebut. Bahkan, Perayu gagal membuktikan bahawa kebajikan anak tersebut terabai dan tidak terjamin sepanjang anak tersebut tinggal bersama Responden-responden.
14. Kami juga merujuk kepada kenyataan Perayu dalam Penyataan Defendan di para 51 berkaitan keadaan semasa Responden 1 yang mana Defendan menyatakan *"Plaintif 1 buat masa ini berada dalam keadaan yang baik di mana kehidupan beliau disokong rapat oleh Plaintif 2, Puan Eva Katreena dan saya sendiri"*. Kenyataan Perayu ini membuktikan bahawa Perayu sendiri mengakui bahawa Responden 1 berada dalam keadaan yang baik pada waktu itu.
15. Menurut as-Syeikh Ibnu Muflih ulama dikalangan Mazhab Hambali mendefinisikan iqrar seperti berikut:

هو إظهار الحق لفظاً أو كتابة أو إشارة

Bermaksud

Iqrar ialah menyatakan sesuatu hak samada secara lafaz atau tulisan atau berbentuk isyarat.

16. Mahkamah merujuk takrif ikrar di bawah Seksyen 17(1) Enakmen Undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 iaitu

17(1)Ikrar ialah suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang, secara bertulis atau dengan isyarat, menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap mana-mana orang lain berkenaan dengan sesuatu hak”.

17. Merujuk kes *Mohd Ishak @ Gahsri Mydin lwn Wilderness Centre Sdn Bhd* [2016] 1 LNS 409, Mahkamah memutuskan seperti berikut:

"[26] Section 17 of the Evidence Act 1950 provides that: "An admission is a statement, oral or documentary, which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact, and which is made by any of the persons and under the circumstances hereinafter mentioned.

18. Kami berpendapat bahawa Responden 1 telah mengemukakan pembuktian kukuh melalui Laporan Perubatan bahawa Responden 1 telah sembuh dari penyakit Bipolar Depression yang dihidapinya dan sihat untuk menjaga anak tersebut bahkan Perayu juga tidak membantah kepada pengemukaan Laporan Perubatan tersebut sewaktu perbicaraan. Perayu juga tidak langsung membuktikan dakwaan Perayu bahawa Responden 1 masih menghidapi simptom penyakit tersebut iaitu mengalami kemarahan yang melampau.
19. Kami bersetuju bahawa Perayu mempunyai tanggungan untuk membuktikan dakwaannya sebagaimana kaedah fiqhiyyah iaitu

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه

Bermaksud :

Sesuatu yang telah tetap hukumnya di suatu waktu dinyatakan terus berlaku selama tidak ada dalil sebaliknya.

ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.

Bermaksud:

Sesuatu yang ditetapkan berdasar keyakinan tidak akan bisa diruntuhkan kecuali dengan keyakinan.

20. Tn. Hj. Mohd. Salleh b. Hj. Ahmad, dalam bukunya Qawa'id al-Fiqhiyyah di halaman 590-591 menghuraikan maksud kaedah seperti berikut: "Umumnya diketahui bahawa al 'adam (tiada) iaitu adalah lebih dahulu daripada al 'wujud (ada), maka setiap sesuatu yang didakwa muncul dan wujudnya bererti ia di dahului oleh al-a'dam. Justeru itu maka al-'adam yang mendahului ke atas al-wujud yang didakwa itu telah sabit dengan yakin, sementara benda yang didakwa wujud sebelum dibuktikan adalah masyquq fihi (diragui) sedangkan keyakinan sesuatu perkara tidak boleh dihilangkan dengan zan lawannya sahaja. Oleh yang demikian maka al 'adam itulah yang diyakini kerana ia sesuatu keadaan yang tabi'e dan perubahan kepada wujud itu sesuatu perkara yang baru diragukan, lagipun al 'adam itulah yang asal, maka mesti dikekalkan hingga terbukti sabit sesuatu yang menghilangkannya."
21. Berdasarkan kaedah fiqhiyyah di atas dan kegagalan pembuktian oleh Perayu bahawa Responden 1 masih mengalami simptom penyakit Bipolar Depression dengan mengalami kemarahan yang melampau, Kami berpegang bahawa Laporan perubatan bertarikh 26/10/2016 tersebut telah menjelaskan dan dengan sendirinya menolak dakwaan Perayu terhadap Responden 1. Bahkan, Perayu juga gagal membuktikan bahawa kemarahan melampau yang dihadapi Responden 1

telah memberikan kesan kepada kebajikan dan penjagaan anak tersebut.

22. Selain itu, Perayu menghujahkan bahawa Responden-responden hilang kelayakan sebagai hadhanah anak tersebut kerana wujudnya kecederaan ke atas anak tersebut sepanjang di bawah jagaan Responden-responden merujuk kepada seksyen 84(e) Enakmen undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 iaitu hak seseorang perempuan terhadap hadhanah adalah hilang jika perempuan itu mencuaikan atau menganiaya kanak-kanak itu.
23. Hasil pengamatan Kami dalam isu ini, Kami bersetuju bahawa Perayu tidak pernah memplidkan berkaitan kecederaan yang menimpa anak tersebut di mana-mana peringkat pliding Perayu sama ada pembelaan mahupun tuntutan balas. Malah, Kami dapati Perayu hanya mengetahui mengenai kecederaan yang menimpa anak tersebut pada 28/1/2017 iaitu anak tersebut mengalami kecederaan lebam mata dan pada 26/5/2017 iaitu kuku ibu jari anak tersebut mengalami kesan lebam yang mana tarikh-tarikh kecederaan tersebut berlaku setelah tamatnya tempoh pemfailan pliding. Responden-responden telah memfailkan jawapan kepada pembelaan dan pembelaan kepada tuntutan balas pada 28/11/2016. Tiada permohonan pindaan pliding dibuat oleh Perayu bagi memasukkan fakta berkaitan kecederaan tersebut.
24. Merujuk kepada kes *Green Land Builders Sdn Bhd lwn Tan Chee Who*, Hakim memutuskan bahawa dakwaan bahawa kontrak di antara Plaintiff dan IT SB tidak sah telah gagal diplidkan di dalam pliding Defendan. Oleh itu, Mahkamah berpendapat bahawa hujah Defendan telah menyimpang daripada pliding asal atas kegagalan Defendan untuk memplidkan fakta-fakta tersebut. Hakim dalam para 72 memutuskan

“(72) Oleh itu Mahkamah terpaksa mengabaikan hujahan Defendan atas

isu illegality of contract kerana Mahkamah tidak mempunyai kuasa untuk memutuskan isu yang tidak diplidkan. Ini kerana pihak-pihak dan juga Mahkamah terikat dengan pliding yang difailkan.”

25. Mahkamah merujuk kes *Cheong Heng Loong Goldsmiths (KL) Sdn Bhd & Anor lwn Capital Insurance Bhd and another* (2004) 1 MLJ 353 (CA) dimana Gopal Sri Ram JCA (pada ketika itu) memutuskan berikut:

“once a defendant takes that course, he must stand or fall on his pleaded case. He cannot simultaneously put forward an unpleaded case of justification for his conduct.”

26. Prinsip ini jelas terpakai kepada Perayu bahawa jika Perayu ingin bergantung dan mendakwa Responden-responden telah hilang kelayakan kerana kecuaiian menjaga anak sehingga menyebabkan kecederaan, maka fakta ini terlebih dahulu mestilah diplidkan. Namun tiada pindaan pliding dibuat oleh Perayu untuk memasukkan fakta tersebut.
27. Kami berpendapat bahawa Mahkamah hanya terikat kepada sesuatu perkara yang diplidkan sahaja. Malah kecederaan yang dialami oleh anak tersebut tidak dibuktikan berpunca dari kecuaiian Responden-responden dalam menjaga anak tersebut.
28. Melalui penelitian kami terhadap Rekod Rayuan, kami tidak menemui apa-apa bukti yang menunjukkan sikap kemarahan melampau Responden 1 ini telah memudharatkan anak tersebut sehingga mampu menghilangkan kelayakan Responden 1 sebagai hadhinah. Sebaliknya apa yang dibangkitkan oleh Perayu hanya atas asas kebimbangan dan kerisauan terjadinya kemudharatan terhadap anak tersebut semata-mata tanpa kepastian.

29. Perayu juga menyangkal kelayakan Responden-responden sebagai penjaga kekal anak tersebut kerana telah berlaku perubahan tempat tinggal anak tersebut. Perayu mendakwa bahawa Responden-responden telah berpindah ke alamat baru yang disembunyikan dari pengetahuan Perayu. Perayu menyatakan perpindahan tempat tinggal anak tersebut boleh menghalang Perayu untuk mengetahui tempat tinggal seterusnya menjalankan pemantauan terhadap anak tersebut.
30. Kami meneliti alasan penghakiman YA Hakim Bicara di para 20 halaman 130 Rekod Rayuan yang menyatakan Responden 1 masih tinggal di rumah beralamat 186, Jalan G1, Taman Melawati, 53100 Kuala Lumpur. Kami turut meneliti catatan perbicaraan di peringkat soal balas Plaintiff pada 18 Julai 2016 di mana Responden 1 menyatakan masih tinggal di rumah tersebut dan hanya akan berpindah setelah kes hak jagaan anak selesai. Responden 1 mengaku telah mengiklankan rumah tersebut untuk jualan namun masih tiada pembeli. Responden 1 turut menyatakan bahawa Responden 1 tidak akan berpindah ke negeri yang lain.
31. Merujuk kepada Kes Rayuan Syariah Selangor, *Abdul Malek b Abdul Kadir lwn Zulzilawati bt Jusoh* (Kes Rayuan No: 10000-028-0084-2016), berkaitan seorang perempuan/ibu hilang kelayakan sebagai penjaga jika dibuktikan bahawa dia mempunyai niat untuk menghalang bapa anak tersebut menjalankan pengawasan perlu ke atas anaknya. Panel hakim memutuskan bahawa

Pada hemat kami, Perayu telah gagal membuktikan bahawa perpindahan Responden dari Bukit Mahkota ke Dungun adalah bertujuan untuk menghalang Perayu sebagai bapa melakukan pengawasan perlu ke atas anaknya. Kami bersetuju dengan hujah Responden bahawa perpindahan tersebut adalah disebabkan tugas

kerja Responden sebagai seorang pensyarah yang telah menamatkan pengajiannya dan perlu kembali ke tempat asal bertugas. Kami mendapati adalah menjadi fakta yang diakui bahawa Responden telah bertugas di UITM Dungun sejak dari awal perkahwinan lagi.

32. Kami berpendapat bahawa beban pembuktian adalah terletak kepada Perayu bagi membuktikan dakwaan bahawa Responden-responden telah berpindah rumah dan dengan niat menghalang pemantauan dijalankan ke atas anak tersebut oleh Perayu.
33. Di dalam kes ini, anak yang menjadi subjek pertikaian adalah seorang anak lelaki yang dilahirkan pada 28/3/2014 yang berumur dalam lingkungan 2 tahun 4 bulan semasa permohonan hadhanah di failkan dan 5 tahun 11 bulan sewaktu keputusan Mahkamah Tinggi Syariah dibacakan. Adalah menjadi anggapan undang-undang bagi kanak-kanak kecil, ibu adalah orang paling berhak menjaga anaknya. Seksyen 82 Enakmen Keluarga Islam (Selangor) 2003 memperuntukkan:

82(1): Tertakluk kepada seksyen 83, ibu adalah yang paling berhak dari segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan.

34. Anggapan ini telah memberikan kedudukan yang positif kepada Responden sebagai ibu kepada anak tersebut. Namun demikian anggapan ini boleh dipatahkan jika isu ketidaklayakan seseorang penjaga dibawah seksyen 84 dapat dibuktikan. Dalam hal ini, Perayu sebagai Defendan telah mempertikaikan kelayakan Responden sebagai penjaga dalam pembelaannya. Oleh itu beban tersebut perlulah ditanggung oleh Perayu berdasarkan seksyen 73 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Selangor 2003. Seksyen 73 tersebut berbunyi:

(1) Sesiapa yang berhasrat supaya mana-mana Mahkamah memberikan penghakiman tentang apa-apa hak atau tanggungan di sisi undang-undang yang bergantung kepada kewujudan fakta yang ditegaskan olehnya, mestilah membuktikan bahawa fakta itu wujud.

(2) Apabila seseorang terikat untuk membuktikan kewujudan apa-apa fakta, maka dikatakan bahawa beban membuktikan terletak pada orang itu.

35. Kami berpuashati bahawa Perayu telah gagal mengemukakan bukti bahawa Responden-responden telah hilang kelayakan sebagai hadhinah anak tersebut. Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa YA Hakim Bicara tidak *terkhilaf* terhadap isu ini.

Isu Kedua : Kewajaran memberikan hak bersama dan bermalam kepada Perayu.

36. Bagi isu ini, Perayu menyatakan bahawa YA Hakim Bicara *terkhilaf* apabila hanya menetapkan hak lawatan sahaja tanpa bermalam kepada Perayu iaitu sebanyak sekali dalam seminggu dan ditetapkan pada setiap hari Ahad. YA Hakim sewajarnya mengulas dalam Alasan penghakimannya berkaitan alasan Perayu hanya diberikan hak lawatan harian dan bukannya hak bermalam bersama anak tersebut.
37. Berhubung isu akses lawatan atau ziarah ini dititipkan oleh Allah s.w.t dengan firmanNya dalam Surah Al-Baqarah: ayat 233 yang bermaksud:-

"... janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya, dan (jangan juga menjadikan) seseorang bapa itu menderita kerana anaknya..."

38. Merujuk kepada kitab *Ahkam Al-Usrah Fi Al-Islam*, hlm. 452 menyatakan:-

من الموضوعات المرتبطة بالحضانة حق رؤية الأب لولده وهو في حضانة النساء ، وحق رؤية الأم لولدها إذا كان مع أبيه أو مع مستحق للحضانة غيرها ، فلا يحق للحاضن أو للحاضنة أن يمنع الأب أو الأم من رؤية الصغير

Maksudnya: "Subjek penting berhubung dengan hadhanah ialah kedudukan seorang bapa tentang hak melawat anaknya yang berada di bawah jagaan bekas isterinya, atau hak seorang ibu melawat anaknya yang masih berada di bawah jagaan bekas suaminya atau orang yang lain yang telak diperintahkan oleh Mahkamah menjaga anak tersebut. Maka hukumnya tidak boleh bagi penjaga anak tersebut menghalang kepada bapa atau ibu untuk melawat anak tersebut"

39. Bagi kitab *Nizam Al-Usrah Al-Islam*, Jilid 3, hlm. 381 menyatakan mengenai situasi anak belum *mumaiyyiz* iaitu:-

"Al-Syafieyyah dan Al-Hanabilah: Bapa mempunyai hak menziarah anak dalam jagaan ibunya selagi belum sampai umur anak itu untuk membawa pilihan dan tidak boleh meminta agar anak dibawa kepadanya"

40. Merujuk kepada kes Noraini Binti Hanipah *Iwn. Nasruddin Shah Bhagjit Bin Abdullah*, JH XXIII (1), hlm. 100 menyatakan bahawa:-

"Hak berjumpa atau ziarah anak-anak bagi pihak ibu bapa adalah sebagai satu ketetapan syara' kerana ia dikategorikan sebagai merapatkan hubungan silaturrahim yang disuruh oleh agama Islam"

Hak bermalam (hari kebiasaan)

41. Kami merujuk kepada Pembelaan dan Tuntutan Balas dan mendapati Perayu hanya memohon berkaitan hak lawatan harian dan bukannya hak bermalam bersama anak tersebut. Namun Perayu ada memohon hak bermalam bersama anak tersebut pada hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha iaitu bermula 5.30 petang sehari sebelum hari Raya Aidilfitri dalam tahun hijrah pada tahun ganjil sehingga jam 5.30 petang pada hari Raya Aidilfitri yang pertama dan bagi Hari Raya Aidiladha iaitu bermula jam 5.30 petang sehari sebelum Hari raya Aidiladha pada tahun genap sehingga jam 5.30 petang pada hari Raya Aidiladha yang pertama.
42. Kami mengingatkan Perayu bahawa mahkamah terikat kepada fakta-fakta yang diplidkan sahaja semasa perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah. Oleh itu, Perayu telah mengemukakan fakta baru di dalam rayuan ini dan ini tidak dibenarkan dalam proses perundangan. Tindakan Perayu ini merupakan satu tindakan yang diklasifikasikan sebagai *afterthought* oleh undang-undang.
43. Pemikiran semula atau *afterthought* merupakan satu isu baru yang ditimbulkan oleh Perayu dalam rayuannya yang mana isu ini tidak dimasukkan dalam pembelaan dan tuntutan atau mana-mana pindaan pliding sebagaimana dalam kes Lai Fee & Anor *lwn* Wong Yu Vee & Ors yang mana Panel Hakim Mahkamah Persekutuan telah memutuskan berkaitan prinsip *afterthought* iaitu

[65] Sebaliknya, pembelaan yang berbentuk pemikiran kemudian (afterthought) merupakan pembelaan yang direka dan diwujudkan

semata-mata untuk menimbulkan satu pembelaan. Ia hanya ditimbulkan semasa perbicaraan kes pembelaan tetapi tertuduh tidak pernah kemukakan pembelaan tersebut kepada pegawai penyiasat semasa siasatan dijalankan dan tidak pernah dikemukakan dalam kes pendakwaan semasa saksi-saksi pendakwaan di soal balas.

44. Pada hemat kami, forum yang paling sesuai untuk menentukan hak bermalam bersama anak tersebut pada hari-hari biasa adalah di dalam kes Tuntutan Ubah Perintah / Penghakiman yang boleh dimohon oleh pihak-pihak di bawah seksyen 76 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 di Mahkamah Bicara sama ada untuk mengubah hak penjagaan atau mengubah apa-apa terma dan syarat perintah / penghakiman terdahulu.

Hak bermalam pada musim perayaan

45. Berkaitan dengan hak bermalam sewaktu perayaan Aidilfitri dan Aidiladha, Kami merujuk pendapat YA Hakim bicara di para 26 Alasan Penghakiman yang menyatakan berkaitan pandangan syarak bahawa anak lelaki dan perempuan yang belum mumaiyiz yang tidak dipisahkan dengan ibunya, mereka dikehendaki berada disisi ibu mereka pada siang dan malam manakala bapa diberikan hak menziarahi anak tersebut.
46. Sukacita kami jelaskan bahawa asas hak ziarah atau lawatan dinyatakan dalam undang-undang berdasarkan peruntukan seksyen 88 (2)(c) dan (d) EUUKIS 2003 sepertimana berikut –

1) ...

2) Tanpa menyentuh keluasan subseksyen (1), sesuatu perintah jagaan boleh –

(a) ...;

(b) ...;

(c) *mengadakan peruntukan bagi kanak-kanak itu melawat ibu atau bapa yang tidak diberi jagaan atau seseorang dari keluarga ibu dan bapa yang telah mati atau tidak diberi jagaan pada masa-masa dan bagi apa-apa tempoh sebagaimana yang difikirkan munasabah oleh Mahkamah;*

(d) *memberi ibu atau bapa yang tidak diberi jagaan atau seseorang dari keluarga ibu atau bapa yang telah mati atau tidak diberi jagaan hak untuk berjumpa dengan kanak-kanak itu pada masa-masa dan dengan seberapa kerap yang difikirkan munasabah oleh Mahkamah; atau*

(e) ...

47. Berdasarkan peruntukan seksyen 88 (2) (c) dan (d) EUUKIS 2003 tersebut jelas menunjukkan bahawa seorang bapa atau ibu yang tidak diberikan hak jagaan anak hendaklah tidak dihalang untuk menziarahi atau melawat anak yang tidak berada dalam jagaan mereka termasuklah hak untuk bermalam. Walaupun tiada peruntukkan undang-undang dan Hukum Syarak yang menyebut secara khusus berhubung tentang hak bermalam, kami berpendapat bahawa hak ini masih boleh dijadikan terma perintah / penghakiman di dalam kes-kes berkaitan dengan hak jagaan anak.

48. Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam *Kes Maizatul Aznin Binti Mohamed lwn. Salihin Bin Ismail* Kes Rayuan (Selangor) No.: 10000-028-0046-2017 telah mengulas berkaitan dengan hak bermalam ini sepertimana berikut -

[21] Hasil penelitian kami, walaupun tiada peruntukan undang-undang dan Hukum Syarak yang menyebut secara spesifik berhubung hak bermalam namun mengikut kaedah uruf dan di dalam perintah-perintah hadhanah, Hakim-Hakim Syarie sebelum ini juga, telah meluluskan permohonan berkaitan hak bersama, dan hak bermalam

dengan anak-anak yang tidak dalam hak jagaannya. Di samping itu, Mahkamah juga mempunyai kuasa budi bicara dalam menyelesaikan pertikaian penjagaan anak sebagaimana dalam seksyen 88 2(c) dan (d) Enakmen Undang- Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

[22] Pada pandangan kami, Responden juga berhak untuk mendapat hak bersama dan bermalam dengan anak ketiga tersebut memandangkan anak tersebut tidak di bawah jagaannya, bahkan perintah yang diputuskan oleh Yang Arif Hakim Bicara adalah perintah yang relevan dan wajar demi menjaga hubungan silaturahim dan memberi ruang kepada Responden untuk menjalankan tanggungjawab mendidik anak ketiga tersebut serta dapat mengeratkan hubungan yang rapat dengan adik beradik yang lain. Kami tegaskan bahawa hak bermalam yang diberikan kepadaibu atau bapa yang tidak diberikan hak jagaan tersebut adalah merupakan suatu tuntutan yang wajar dan munasabah yang tidak wajar dipertikaikan oleh Perayu di dalam kes ini memandangkan berdasarkan perundangan keluarga Islam di Mahkamah-Mahkamah Syariah, tuntutan berhubung hak bermalam adalah dibenarkan berdasarkan keperluan yang difikirkan suaimanfaat oleh Mahkamah.

49. Walau bagaimanapun, kami berpandangan bahawa YA Hakim Bicara boleh menggunakan budi bicaranya untuk memberikan hak bermalam kepada Perayu bersama anak tersebut pada musim perayaan meskipun tiada dalil syarie yang jelas membicarakan tentang hak bapa untuk bermalam dengan anaknya terutamanya anak yang belum mumaiyiz.
50. Pada hemat kami, bagi menjaga kebajikan dan hubungan silaturrahim di antara Perayu dengan anak tersebut, kami berpendapat bahawa hak lawatan ziarah/lawatan yang diberikan sewajarnya tidak menafikan hak untuk Perayu bermalam dengan anak tersebut. Oleh yang demikian, Kami percaya YA Hakim Bicara telah *terkhilaf* dalam memutuskan perkara ini dan ianya merupakan sebab yang patut untuk kami campur tangan terhadap penghakiman terdahulu.

Isu Ketiga : Kewajaran YA Hakim Bicara mempertimbangkan atau mengulas setiap tuntutan balas Perayu untuk dijadikan sebagai terma penghakiman.

51. Bagi isu ini, Perayu menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara telah *terkhalaf* apabila tidak mempertimbangkan setiap tuntutan balas Perayu untuk dijadikan sebagai terma penghakiman.
52. Merujuk kepada Alasan Penghakiman di hlm 122-135 Rekod Rayuan, kami dapati YA Hakim Bicara tidak mengulas secara terperinci mengapa terma-terma dalam Tuntutan Balas tidak dimasukkan di dalam Penghakiman Hadhanah tersebut.
53. Bagi isu penambahan terhadap terma-terma tersebut, kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa semasa kes rayuan ini didengar, umur anak tersebut telah meningkat dari 2 tahun 4 bulan kepada 5 tahun 11 bulan semasa keputusan Mahkamah Tinggi Syariah diberikan pada 20/2/2020. Justeru itu, kami berpendapat penentuan hak dan terma lawatan yang bersesuaian dan adil atau penambahan terhadap terma-terma Penghakiman Hadhanah tersebut tidak dapat ditentukan oleh kami pada hari ini kerana kami tidak berpeluang untuk mendengar dan meneliti keterangan langsung pihak-pihak, lebih-lebih lagi dalam situasi telah berlakunya perubahan matan terutamanya terhadap kondisi umur anak tersebut serta perubahan terhadap tempoh masa.
54. Kami kemukakan pandangan YA Hakim Bicara di dalam kes *Charlotte Mary Erica Leng Iwn. Anis Sani Bin Ariffin, JH 47(2)* bahawa kedua-dua pihak hendaklah mematuhi apa-apa perintah / penghakiman yang dikeluarkan oleh Mahkamah tanpa engkar agar proses pelaksanaan perintah Mahkamah berjalan lancar. Kedua-dua pihak juga hendaklah memberikan kerjasama dalam memastikan kebajikan dan kemaslahatan anak tersebut terjaga tanpa

halangan antara satu sama lain bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing sebagai ibu dan bapa kepada anak tersebut.

55. Kami juga kemukakan pandangan Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Kelantan di dalam kes *Mohd Radhi bin Haji Che Daud lwn Khadijah binti Yaacob*[2004] JH 17(1) sebagai renungan bersama iaitu -

“Tujuan hadhanah atau penjagaan kanak-kanak ialah untuk masalah dan kebaikan kanak-kanak yang dipelihara sebagai hak asasi bagi kanak-kanak itu dan hak itu mesti diutamakan lebih dari hak pihak yang ingin memelihara mereka.”

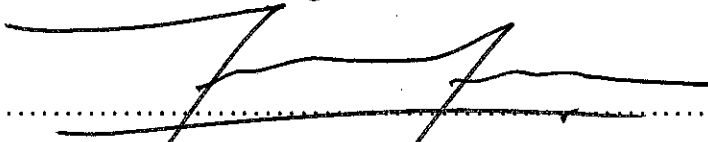
KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan meneliti hujahankedua-dua belah pihak, **MAKA KAMI MEMUTUSKAN** sebagaimana berikut -

1. Rayuan Perayu adalah **DITOLAK**
2. Penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 20/2/2020 melalui **Kes Saman No. 10400-028-0471-2016** adalah **DIKEKALKAN**
3. Perayu (Defendan) diberikan hak untuk bersama dan bermalam dengan anak tersebut pada hari Raya Aidilfitri bagi tahun hijrah yang ganjil mulai 1445H. Anak tersebut boleh diambil mulai jam 5.30 petang sehari sebelum hari Raya Aidilfitri dan diserahkan semula anak tersebut kepada Responden selewatnya jam 5.30 petang pada hari Raya Aidilfitri yang pertama.
4. Perayu (Defendan) diberikan hak untuk bersama dan bermalam dengan anak tersebut pada Hari Raya Aidiladha dalam tahun hijrah yang genap mulai 1444H. Anak tersebut boleh diambil mulai jam 5.30 petang sehari sebelum Hari raya Aidiladha dan diserahkan semula anak tersebut kepada Responden selewatnya jam 5.30 petang pada hari Raya Aidiladha yang pertama.

5. Kos ditanggung oleh masing-masing

Di baca dan ditandatangani oleh:-


.....
YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSSAIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

Set. 7 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Negeri Selangor 2013.
.....
YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor